



DELIBERA N. 59

7 febbraio 2024

Oggetto

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, presentata da Università degli Studi di Cagliari – Procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della L. 120/20, mediante Richiesta di offerta in Piattaforma MePA, per l'affidamento dei lavori di adeguamento antincendio dei Blocchi B, C, D, F, G e H della Cittadella Universitaria di Monserrato - CIG: 9894287FEA - Importo a base di gara: € 3.984.677,93 - Criterio d'aggiudicazione: minor prezzo - S.A.: Università degli Studi di Cagliari
UPREC-PRE 808/2023/L/PREC PB - FASC. 5805/2023

Riferimenti normativi

art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016

art. 93, d.lgs. 50/2016

Parole chiave

Appalto – garanzia provvisoria - polizza fideiussoria - importo insufficiente – appendice – esclusione - soccorso istruttorio – condizioni

Massima

appalto pubblico – in genere – scelta del contraente – gara – garanzia provvisoria – importo insufficiente - soccorso istruttorio – ammissibilità - esclusione - illegittimità

È sanabile mediante soccorso istruttorio la polizza fideiussoria d'importo inferiore a quello richiesto dalla lex specialis; l'offerente che ha presentato una polizza fideiussoria d'importo insufficiente non può essere escluso senza essere prima ammesso all'esercizio del soccorso istruttorio

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 7 febbraio 2024



DELIBERA

VISTA l'istanza del 10 novembre 2023 prot. n. 100438, con cui l'Università degli Studi di Cagliari ha chiesto un parere sulla correttezza del proprio operato in relazione all'esclusione dalla procedura di gara in oggetto del costituendo RTI Nuova CCS s.r.l./Costruzioni Angelico edili stradali s.r.l. (di seguito, RTI) senza ricorso al soccorso istruttorio, per aver questi presentato una garanzia provvisoria d'importo inferiore a quello richiesto negli atti di gara, esclusione che il RTI ha contestato;

VISTA la memoria della SA con cui quest'ultima ha chiarito di aver disposto l'esclusione del RTI il 23.10.2023 senza ricorrere al soccorso istruttorio perché, in adesione al richiamato orientamento giurisprudenziale, ritenuto maggioritario, lo ritiene inammissibile al fine di sanare l'omessa o irregolare presentazione della cauzione provvisoria; pertanto, l'esclusione è conforme alla legge. Sostiene, inoltre, che anche ricorrendo al soccorso istruttorio il RTI sarebbe stato escluso perché dopo l'esclusione ha prodotto una polizza con l'importo esatto ma emessa il 24.10.2023, ossia in data successiva al termine di presentazione delle offerte; dunque, diversamente operando, si sarebbe ammessa la produzione di nuova documentazione dopo tale termine, in violazione dei «principi di immutabilità e segretezza dell'offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti»;

VISTA la nota del RTI escluso che ha evidenziato che l'eccezione sollevata dalla SA sulla rinnovata costituzione della cauzione, "non consentita in quanto perfezionatasi oltre il termine previsto per la presentazione dell'offerta alla procedura di gara, non è stata motivo d'esclusione, né è stata sollevata prima, risultando quindi tardiva, oltre che infondata; a riprova di ciò, ha allegato l'appendice di polizza (n. 2) emessa il 10.11.2023, a integrazione della polizza presentata in offerta (n. 2023/13/6662262), che precisa espressamente che «la somma garantita deve intendersi di euro 16.000,00 sin dall'origine della polizza emessa con effetto 27.07.2023»;

VISTO l'avvio del procedimento avvenuto in data 12 dicembre 2023;

VISTA la memoria del RTI escluso che, nel ricostruire le vicende occorse, ha rappresentato che: a) la sua esclusione del 23.10.2023 è stata motivata con il fatto che la sua offerta era corredata da una garanzia provvisoria dell'importo di € 15.938,72 anziché di € 16.000,00, ritenuta dalla SA insuscettibile di soccorso istruttorio perché parte essenziale ed integrante dell'offerta; b) ha contestato immediatamente l'esclusione sulla base del richiamato e consolidato orientamento dell'Autorità, producendo contestualmente un'appendice di polizza (n. 1) emessa il 24.10.2023 a integrazione della polizza presentata in offerta (n. 2023/13/6662262), con l'importo esatto; c) ha prodotto, dopo la richiesta di parere della SA, una appendice di polizza (n. 2) emessa il 10.11.2023, con cui la compagnia assicurativa ha espressamente dichiarato che «la somma garantita deve intendersi di euro 16.000,00 sin dall'origine della polizza emessa con effetto 27.07.2023». Il RTI ha precisato anche che l'importo originario, inferiore di soli 61,28 euro rispetto a quello esatto, era stato calcolato erroneamente dalla compagnia assicurativa sull'importo posto a base di gara anziché su quello comprendente gli oneri di sicurezza, risultando un evidente errore involontario della stessa. Ha richiamato i precedenti dell'Autorità e della giurisprudenza sulle stesse fattispecie, citati dalla SA ma in modo distorto poiché nel caso in esame la par condicio tra i partecipanti è stata garantita, non avendo il RTI presentato la garanzia provvisoria dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ma prima; come dimostrato dalle appendici di polizza prodotte, la garanzia è stata prestata per l'importo di € 16.000,00 sin dall'origine, ossia dal 27.07.2023. L'appendice di polizza del 10.11.2023 si limita a precisare, infatti, l'importo garantito dalla polizza 'originaria', già



corretto con l'appendice del 24.10.2023, e la sua decorrenza, posto che l'appendice non è una nuova polizza ma un'integrazione di quella originaria, che resta valida sin dalla sua emissione. Il provvedimento di esclusione sarebbe, dunque, da ritenersi illegittimo e il RTI avrebbe diritto a essere riammesso alla gara;

VISTO il 'Regolamento in materia di pareri di precontenzioso, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 10 del 09.01.2019, come modificato con delibera n. 528 del 12.10.2022, che continua ad applicarsi alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'art. 18 del "Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 220 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", approvato con delibera n. 267 del 20.06.2023;

VISTI gli atti e la documentazione di gara;

VISTO il provvedimento di esclusione del RTI del 23.10.2023 (prot. n. 239304) che indica in motivazione che «la garanzia allegata all'offerta [...] è stata costituita per un importo inferiore al 1% dell'importo complessivo dell'appalto o ad altro inferiore importo determinato sulla base dell'art. 93, comma 7, del Codice» (d.lgs. 50/2016), in cui si dà atto che nella seduta del 05.09.2023 è emerso che la garanzia provvisoria «è inferiore all'importo richiesto dalla Stazione appaltante (€ 16.000,00)» e che «la carenza di un simile requisito dell'offerta, essenziale secondo la legge di gara, giustifica l'esclusione senza violazione del principio di tassatività delle relative cause», tenuto conto delle previsioni del disciplinare di gara e dell'orientamento giurisprudenziale che qualifica la garanzia provvisoria come parte essenziale e integrante dell'offerta e, dunque, insuscettibile di soccorso istruttorio;

VISTO l'art. 13 del disciplinare di gara che prevede che «sarà sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria [...] solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. Sarà onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano stati costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. [...] Non sarà sanabile e, quindi, sarà causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante»;

CONSIDERATO il consolidato orientamento dell'Autorità (cfr. per tutte, delibere n. 151 del 19.04.2023, n. 212 del 27.04.2022, n. 43 del 02.02.2022, n. 765 del 24.11.2021, n. 589 del 28.07.2021) e il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. per tutte, da ultimo, TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 30/08/2023; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 03/04/2023, n. 2075; Consiglio di Stato, Sez. V, 22/11/2022, n.10274; id., 03.08.2021, n. 5710; id., 19/04/2021, n. 3166; id., n. 399/2020), che hanno affermato l'esperibilità del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, co. 9, d.lgs. 50/2016, in ogni caso di carenza/irregolarità della cauzione provvisoria, incluso il caso di mancanza, d'erronea modalità di presentazione e d'importo insufficiente, rientrando, dunque, in tale fattispecie, il caso di una polizza validamente costituita, con indicazione di un importo inferiore rispetto a quanto prescritto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17/09/2021, n. 6324; id., 22/07/2019, n. 5138);

CONSIDERATO il parere di precontenzioso con cui l'Autorità ha affermato che «La polizza fideiussoria stipulata anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e prodotta unitamente alla documentazione amministrativa, recante un importo insufficiente può essere sanata tramite il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, la quale deve consentire all'operatore economico di integrarne l'ammontare», precisando che la giurisprudenza amministrativa ha sostenuto che il principio, «per il quale il soccorso istruttorio va a buon fine con conseguente permanenza in gara dell'operatore solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria sia di data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione, va limitato alla sola ipotesi di mancanza della cauzione provvisoria, quando questa sia richiesta dalla legge di gara come elemento essenziale della domanda a



pena di esclusione» mentre «la mera irregolarità della fidejussione tempestivamente costituita, determinata dall'ammontare rivelatosi insufficiente, può essere sanata tramite il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, che dovrebbe consentire all'operatore economico di integrarne l'importo» (delibera n. 43/2022);

CONSIDERATO, altresì, il parere di precontenzioso con cui l'Autorità ha affermato che «Sana le carenze documentali rilevate dalla SA, l'offerente che a seguito dell'esperimento del soccorso istruttorio produce, nei termini assegnati, l'appendice alla polizza fideiussoria con l'importo esatto, rilasciata in data successiva al termine di presentazione dell'offerta» e che «Non è conforme alla normativa di settore l'esclusione dalla procedura di gara dell'offerta che, all'esito del soccorso istruttorio, risulti provvista della fideiussione provvisoria con l'importo esatto indicato nella *lex specialis*» (Delibera n. 151 del 19.04.2023)

RITENUTO che il RTI ha presentato una garanzia provvisoria costituita mediante polizza fideiussoria emessa in data 27.07.2023, d'importo insufficiente in quanto inferiore di € 61,28 a quanto richiesto negli atti di gara e che la SA non ha attivato il dovuto soccorso istruttorio al fine di consentire al RTI d'integrarne l'importo, procedendo alla sua esclusione in violazione, oltre che della normativa di settore, della *lex specialis* che esplicitava solo i termini di sanabilità della mancata presentazione della garanzia provvisoria tramite soccorso istruttorio (individuandoli nella avvenuta costituzione della polizza in data antecedente alla della presentazione dell'offerta), ma nulla specificava per l'ipotesi di garanzia d'importo insufficiente;

CONSIDERATO che il RTI ha corredato l'offerta, sin dalla sua presentazione di una polizza fideiussoria, seppur di importo non corretto, e successivamente, ha peraltro prodotto un'appendice di polizza (n. 1) con l'importo esatto e un'appendice (n. 2) con la precisazione della decorrenza della garanzia, per l'importo corretto, sin dalla data di emissione della polizza 'originaria', ossia il 27.07.2023, conformemente agli orientamenti giurisprudenziali e dell'Autorità sopra richiamati, l'operatore economico avrebbe dovuto essere ammesso a soccorso istruttorio per sanare l'irregolarità della polizza fideiussoria che corredeva la sua offerta;

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che l'esclusione dalla procedura di gara in oggetto del costituendo RTI Nuova CCS s.r.l./Costruzioni Angelico edili stradali s.r.l., non sia conforme alla normativa di settore, poiché quest'ultimo avrebbe dovuto essere ammesso a soccorso istruttorio per sanare l'irregolarità della cauzione provvisoria prodotta in gara.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 13 febbraio 2024

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente